

1500119-71.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente o fato de o local já ser conhecido como ponto de tráfico, a informação recebida pelos policiais, de uma moradora, indicando que o réu vinha realizando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500119-71.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500119-71.2022.8.26.0047 - 2022/000091

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GUILHERME BERNINI DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito: Dr. RICARDO BAREA BORGES

Vistos.

1. JOÃO GUILHERME BERNINI DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos (fl. 6), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 324 (trezentos e vinte e quatro) porções de cocaína, com peso líquido total de 121,68 g (cento e vinte e um gramas e sessenta e oito centigramas) [fls. 106/108].

Não houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal (fls. 104/105).

O acusado foi notificado (fl. 136) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 155/156), a denúncia foi recebida (fls. 158/159).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu interrogado (fls. 204/205 e 227).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fl. 227).

A d. Defensora apresentou memoriais arguindo, preliminarmente, pela nulidade da prova obtida através da análise do celular do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, pelo

reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 228/235).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Da alegação de ilicitude da prova obtida dos dados do celular do acusado (fls. 229/230).

Alega a d. Defesa que houve violação à intimidade em razão de os policiais terem lido as notificações que apareceram na tela do aparelho celular do acusado.

Nunca é demais lembrar que a violação à intimidade é acolhida pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, sendo assim, os dados e informações só podem ser acessadas mediante prévia autorização judicial, com fulcro no art. 3º, da Lei nº 9.472/97 e art. 7º, da Lei nº 12.965/14.

Entretanto, in casu, as mensagens foram lidas pela barra notificação do aparelho celular enquanto o aparelho foi devidamente apreendido quando da prisão em flagrante, ou seja, qualquer pessoa em posse do eletrônico poderia visualizar, inclusive os policiais militares no momento da abordagem.

Ressalta-se, ainda, que o acesso efetivo ao aparelho apenas se deu após a prévia autorização judicial de fls. 46/47.

Durante a prisão em flagrante, apenas foi visto as mensagens que chegavam e apareciam de imediato na tela, sendo que o aparelho poderia ter sido configurado pelo usuário para que não fossem exibidas as notificações na tela de bloqueio, mas apenas quando desbloqueado.

Assim, considerando que a visualização foi possível sem a necessidade de senha ou de desbloqueio para conhecimento do teor da informação, e que isso se deu no contexto da prisão em flagrante (oportunidade na qual o aparelho celular e outros objetos de interesse da investigação é apreendido e apresentado na delegacia), diferentemente do sustentado pela d. causídica, o ato dos policiais não incorre em violação da intimidade ou privacidade.

De mais a mais, é certo que os relatos trazidos pelos policiais em relação as mensagens que chegaram no momento da prisão em flagrante não serão utilizados, já que houve a devida produção de laudo pericial, prova esta que seria invariavelmente obtida com o deferimento pelo juízo, como ocorre ordinariamente nos inquéritos em que se apura a conduta de tráfico de drogas nos quais existe apreensão de celular no momento da prisão em flagrante.

Rejeito, destarte, a preliminar arguida, ressaltando que foi deferida a quebra do sigilo de dados das comunicações telefônicas (fls. 44/47).

2.1. Quanto ao mérito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelas fotografias (fls. 21/27), pelos laudos periciais de exame químico-toxicológico (fls. 33/35 e 63/65), pelo laudo de extração de dados de aparelho celular (fls. 77/81 e 83/96).

Na fase policial o acusado aduziu que estava auxiliando seu padraço como ajudante de pedreiro, não tem filhos e chegou a ser apreendido quando era adolescente por tráfico de drogas, cumprindo um ano e alguns dias na Fundação Casa. Quanto aos fatos que lhe estão sendo imputados, informou que os policiais lhe abordaram e encontraram em seu poder apenas dinheiro. Que foi deixado no chão, enquanto dois policiais de moto deram uma volta e o policial que ficou com o interrogando no local ficou mexendo em seu celular. Posteriormente, os policiais das motos voltaram com a droga e dizendo que era do interrogando (fl. 5).

Em Juízo o acusado aduziu que nega os fatos. No dia do ocorrido, estava na casa de um amigo e foi comprar energético no 'Bar do Dito'. Quando estava no meio do quarteirão do estabelecimento, o interrogado foi abordado pelos policiais. Afirma que estava na posse de R\$ 40,00. Nega ter jogado a embalagem com 'coxa' no chão. Foi algemado pelos policiais. O PM Negrini começou a ler as mensagens no celular do acusado. Em seguida, o PM Negrini pediu para que o denunciado desbloqueasse o celular, tendo o interrogado se negado. Em razão disso, o PM Negrini colocou a mão no revólver e ameaçou o denunciado, dizendo 'desbloqueia esse celular senão você já sabe, é eu ou você que vai morrer, já tava querendo prender você faz uns dias'. O interrogado disse ao policial que 'não devia nada para ninguém' e se recusou a

desbloquear o aparelho. Momentos depois, o acusado ficou com um policial na calçada, enquanto outros dois castrenses foram até o terreno e voltaram com a droga. O réu disse que desconhecia o dono da droga e nesse momento o PM Negrini apontou a arma contra a cabeça do denunciado e solicitou que desbloqueasse o celular. Então o interrogado desbloqueou o celular e o policial começou a ler as mensagens. Tem passagem pela Fundação Casa por tráfico de drogas. No dia em que foi preso, fazia alguns dias que estava solto. Só conhecia o PM Paulo Negrini, pois foi o policial que prendeu o acusado em outra oportunidade. Acredita que o PM Negrini tem motivos para incriminar injustamente o réu, pois quando era menor de idade, 'batia de frente' com o policial militar. Nega que tenha confessado aos policiais que estava praticando o tráfico de drogas. Os policiais não pediram autorização para ler ou desbloquear o celular do interrogado. Não acompanhou os policiais até o terreno onde foram localizadas as drogas (fl. 227).

O Policial Militar Negrini obtemperou que já tinha notícias de que o réu traficava, inclusive o depoente já tinha prendido o acusado quando menor de idade. Nessa ocasião, tinha a informação de que o denunciado estaria guardando o entorpecente em um terreno próximo ao bar. Em patrulhamento na modalidade ROCAM, foi possível observar o réu entrando e saindo do terreno com drogas, para posteriormente vender próximo ao 'Bar do Dito'. Foi localizada uma porção de droga em posse do réu e as demais no terreno baldio. A informação recebida pelo depoente descrevia o terreno baldio como depósito da droga vendida pelo acusado. O depoente fez uma breve observação do réu, a fim de descobrir o modus operandi, tendo verificado que o denunciado entrava no terreno, pegava o entorpecente e vendia nas proximidades do 'Bar do Dito'. Viu o acusado ter essa conduta três vezes. Afirma que na ordem de parada, o réu arremessou uma porção de cocaína. Foi encontrado R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) em posse do acusado. Relata que as respostas que o réu apresentava sobre o entorpecente eram desconexas, e que o denunciado dizia que era para uso pessoal, mas não apresentava convicção. Em busca pelo terreno, foi possível localizar o restante das porções da droga, que eram idênticas aquela arremessada anteriormente pelo réu. Afirma que o dinheiro encontrado estava bem amassado e sem organização, típico de traficância, uma vez que normalmente o agente fica nervoso com a conduta e guarda o dinheiro de qualquer jeito. A notícia recebida no dia dos fatos foi informada por uma moradora do local, a qual descreveu o agente como um jovem 'bem branquinho', de óculos e bicicleta. O local era conhecido por tráfico de drogas. Afirma que a conduta criminosa se dava da seguinte maneira: o acusado pegava o dinheiro do usuário, montava na bicicleta e ia até o terreno, buscava a droga e voltava por outro caminho que também dava acesso ao bar e, finalmente, entregava a droga para o indivíduo. Afirma que o celular do acusado ficou bloqueado todo o momento, e que apenas chegavam notificações, que todos podiam visualizar. O depoente chegou a perguntar para o denunciado se o celular era usado para a traficância, mas o réu negou. O acusado não autorizou o acesso ao celular e o depoente também não tentou acessá-lo em nenhum momento (fls. 204/205). O Policial Militar Vitor obtemperou que estava em patrulhamento quando recebeu informação de uma moradora que reside próximo do local dos fatos, que já era conhecido por ser um ponto de drogas, o 'Bar do Dito'. A denúncia falava sobre o indivíduo de o nome de João Guilherme, de apelidos 'Alemão' ou 'Oclinho'. Em observação, o depoente viu o réu fazendo contato com os usuários da via e depois se deslocando até um terreno próximo ao local. O depoente resolveu realizar a abordagem do denunciado, e quando se aproximou do réu, o acusado jogou uma porção de droga no chão. A droga aparentava ser cocaína. Realizada a abordagem, foi encontrado dinheiro nos bolsos da bermuda do réu. O acusado confessou que estaria praticando o tráfico de drogas desde às 18h30 daquele dia. Após a busca pessoal, o depoente se deslocou até o terreno e localizou 323 (trezentos e vinte e três) porções análogas à cocaína, iguais a que o acusado teria descartado durante a abordagem. Durante a abordagem, chegavam várias mensagens no celular do réu de um indivíduo de alcunha 'Coto' perguntando como estavam as vendas. Afirma que essas mensagens chegavam na tela bloqueada do celular. A denúncia foi feita pessoalmente por uma moradora. Acredita que a distância entre o terreno e o bar seja de 80 metros. Disse que a pessoa chegava no bar, dava o dinheiro para o réu e o acusado

ia até esse terreno pegar a droga e depois entregava ao usuário. O acusado autorizou o depoente a ler as mensagens de texto, ainda que na tela bloqueada, porém não se recorda se houve uma autorização por escrito (fl. 227). Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, mormente pelo depoimento dos policiais militares. É sabido que não se pode relegar ao oblivio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos. Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente o fato de o local já ser conhecido como ponto de tráfico, a informação recebida pelos policiais, de uma moradora, indicando que o réu vinha realizando o tráfico, bem como o acusado já ser conhecido nos meios policiais, ressaltando-se a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido, e a apreensão de dinheiro, o que bem demonstra a finalidade de mercancia.

Ainda que, de fato, exista contradição entre alguns pontos trazidos pelos policiais, como apontado pela n. Defensora em suas alegações finais, é certo que isso se dá em relação a elementos acessórios da abordagem (quantos metros os policiais estavam quando da campana; se a denúncia citou apelido do réu ou apenas suas características físicas; o veículo dos supostos usuários que conversado com o réu instantes antes da prisão etc.)

Contudo, quanto aos pontos principais não existiu a mínima contradição entre os policiais, que afirmaram categoricamente que receberam a denúncia com elementos que permitiam uma individualização detalhada do réu; que realizaram a campana e observaram contato dele com ao menos três pessoas, sempre indo buscar algo no terreno vazio após o contato inicial; o encontro de uma porção de cocaína, mais o dinheiro, com o réu, além das drogas embaladas de forma idêntica no terreno baldio em que o réu ia frequentemente pegar algo).

Ademais, é certo que a versão dos policiais vem amparada pelas demais provas produzidas, especialmente o vasto laudo pericial de fls. 77/96 obtido com o celular do réu, que identificou diversas mensagens relacionadas ao tráfico, como às fls. 87,88, 92,93,94 e 95, nas quais inclusive fotos de balança de precisão são apresentadas. Ademais, inclusive nas mensagens é possível verificar o "horário" e local em que o réu atuava, sendo compatível com aqueles em que foi preso (fl. 85)

Ainda, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

Observo, ainda, que a defesa não produziu qualquer elemento concreto que pudesse indicar que os policiais teriam motivo para inventar os fatos e falsamente atribuir a prática do crime pelo réu.

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.2. Passo à dosimetria da pena.

1ª fase: No tocante a primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que a culpabilidade do acusado é inerente à espécie. O réu é primário. Não existem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos e as consequências do crime são inerentes a espécie, nada havendo que ser valorado. O comportamento da vítima, por sua vez, não merece qualquer valoração no caso em análise.

Quanto as circunstâncias do delito, diante da quantidade de droga já embalada individualmente (324 porções), que alimentaria o vício de centenas de pessoas, e considerando a natureza altamente lesiva da referida droga (cocaína), a pena deve ser exasperada.

Nesse ponto, considerando que, de acordo com no art. 42, da Lei 11.343/06, a quantidade e natureza da droga acima reconhecidas no caso em tela são circunstâncias preponderantes na primeira fase da dosimetria, entendo que, no caso, a pena deve ser exasperada em 1/5.

Logo, fixa-se a pena base 1/5 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

2ª Fase: Não há agravante e, em razão da atenuante da menoridade relativa, ora considerada, atenuo a pena em 1/6, tornando a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dia-multa.

3ª Fase: In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, embora seja primário (conta atualmente com 19 anos de idade), já possuía diversas passagem pela Vara da Infância local, sendo ao menos duas delas por ato equiparado ao crime de tráfico, tendo inclusive permanecido internado até poucos dias antes dos fatos (v. Fls. 39 e 41).

Ademais, já era conhecido nos meios policiais, por envolvimento com tráfico de drogas, como relatado pelos policiais, tudo a indicar que não se tratava de mero traficante eventual.

Aliás, o laudo pericial do celular apreendido, já citado na fundamentação acima, não deixa dúvidas da habitualidade e dedicação criminosa do réu ao tráfico de entorpecentes.

Assim, todos esses elementos servem para afastar a minorante.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRADO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou Maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no REsp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de

entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada." (HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010)

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para condenar JOÃO GUILHERME BERNINI DE FIGUEIREDO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais preponderantes desfavoráveis, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 3º do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se as medidas cautelares impostas (fls. 175/176).

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro e do aparelho celular apreendidos – em favor da União (fl. 13), já que o celular nitidamente era utilizado, de forma reiterada, na prática do crime em comento, conforme laudo de fls. 83 e seguintes.

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intím-se e cumpra-se.

Assis, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA